법 학 논 총
제66집, 2026년 9월, 41~78
숭실대학교 법학연구소

Soongsil Law Review
Vol. 66, 2026. Sep., 41~78
Institute for Legal Studies
Soongsil University Seoul, Korea

개인파산에서 파산선고 후 성립한 납부지연가산세의 절차상 지위와 면책

- 기간경과형 조세 부대채권의 분류와 입법적 조정을 중심으로 -

김 민 규*·박 병 재**

<목 차>

Ⅰ. 문제의 제기
Ⅱ. 납부지연가산세의 성립구조와 파산절차상 지위
Ⅲ. 면책 한계와 입법적 조정의 필요성
Ⅳ. 입법모델의 선택과 구체적 설계
Ⅴ. 결론

국문초록

납부지연가산세의 일별 납세의무 성립규정은 2019년 말 개정으로 도입되었고, 2025년 12월 23일 개정된 국세기본법은 2026년 7월 1일부터 지정납부기한 후의 기간경과분을 월별 산정·성립 구조로 전환하였다. 본 글은 파산선고 전 성립한 본세가 미납된 경우, 선고 후 기간경과에 따라 성립하는 납부지연가산세가 파산채권·후순위파산채권·재단채권 중 어디

논문투고일 : 2026. 09. 06. 논문심사일 : 2026. 09. 15. 게재확정일 : 2026. 09. 30.
* 제1저자, 변호사, 고려대학교 도산법연구센터(원외연구위원)
** 참여저자, 서울회생법원 개인회생위원 사무실(인턴)

에 해당하며 면책되는지를 검토한다.

구 가산금·중가산금의 선고 후 발생분을 후순위파산채권으로 본 대법원 2017. 11. 29. 선고 2015다216444 판결의 법리가 현행법에도 적용될 수 있는지가 문제된다. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」(이하 '채무자회생법') 제423조·제446조의 체계와 위 판결이 인정한 지연배상적 성격을 종합하면, 그 기간경과분은 재단채권이 아니라 후순위파산채권으로 보는 것이 타당하다.

다만 국세기본법 제21조에 기한 반대해석의 여지가 있고, 후순위파산채권으로 보더라도 조세는 채무자회생법 제566조 단서 제1호에 따라 면책대상에서 제외된다. 문제의 핵심은 파산선고 후 파산재단을 통한 조세변제를 채무자가 통제할 수 없는 반면, 그 기간의 가산세 미변제액은 면책 후에도 개인책임으로 남는 '변제통제와 책임의 불일치'에 있다. 이에 본 글은 기간경과분을 파산채권으로 편입·후순위화하고 성실한 면책채무자의 미변제잔액에 대해서만 면책을 규정하는 '절차편입·후순위화·제한적 면책형'을 제안하며, 이를 위한 채무자회생법 제423·446·566조의 연계 개정안을 제시한다.

주제어 : 개인파산, 납부지연가산세, 파산채권, 후순위파산채권, 재단채권, 조세 비면책

Ⅰ. 문제의 제기

개인파산은 파산재단을 공정하게 환가·배당하는 절차이자, 면책을 통해 채무자가 경제생활을 다시 시작할 수 있게 하는 제도이다.[1] 현행법은 조세징수의 공익성을 고려하여 조세채권을 면책에서 제외하고 있다. 그러나 파산선고 후 채무자가 파산재단에 속한 재산을 통한 본세의 변제를 스스로 결정할 수 없는 동안에도 납부지연에 따른 부담이 계속 증가하고 그 증가분까지 개인책임으로 남는다면, 면책제도가 지향하는

www.kci.go.kr

1) 헌재 2022. 9. 29. 선고 2019헌마874 결정, 결정이유 4.나.(1)·(2).

경제적 재기와 긴장이 발생할 수 있다.

종래 논의는 구 국세징수법상 가산금·중가산금의 도산절차상 지위를 중심으로 전개되었다. 강상우와 이주헌은 대법원 2017. 11. 29. 선고 2015다216444 판결이 제시한 지연배상금에 관한 법리와 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」[2](이하 '채무자회생법') 제473조 제2호의 문언을 근거로, 파산선고 후 발생한 가산금·중가산금이 후순위파산채권에 해당한다고 보면서 이를 입법으로 명문화할 필요가 있다고 주장하였다.[3] 반면 주진암은 본세와 부대채권의 종속성 및 파산관재인의 불납부를 중시하여 재단채권설을 취하면서도 그 범위를 입법으로 제한할 필요가 있다고 보았다.[4] 이처럼 체납기간에 따라 증가하는 가산금(이하 '기간경과형 가산금')의 법적 지위에 관하여 견해가 대립하였다. 한편 손홍수는 파산절차에서 조세채권에 지나치게 우월한 지위를 부여하는 것이 다른 채권자와의 형평 및 채권자 사이의 공평한 만족이라는 청산절차의 취지에 반할 수 있다고 지적하였다.[5] 이러한 문제 제기는 조세 부대채권의 법적 지위에 관한 논의를 개별 채권의 성질론에 그치지 않고, 조세우선권과 도산절차상 배분적 형평의 관점에서 검토할 필요성을 보여준다.

이 문제를 개별 채권의 법적 성질에 관한 논쟁을 넘어 조세우선권의 정당성과 도산절차상 배분적 형평이라는 정책적 차원에서 다룬 연구도 존재한다. 이의영은 절차관여자의 공동이익에 기여하지 않는 조세 부대채권의 우선순위를 낮추어야 한다고 주장하고, 정지선·이기욱은 가산금을 재단채권 또는 공익채권에서 제외함으로써 일반채권자의 배당을 보호할 필요가 있다고 본다.[6] 임치용 역시 파산선고 전 조세채권이

---

2) 이하 법률명을 별도로 표시하지 않은 조문은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」의 조문을 의미한다.

3) 강상우, "파산선고 전의 원인으로 인한 조세채권에 기하여 파산선고 후에 발생한 가산금의 법적 성질", 『영남법학』 제48호, 2019, 125-127면 및 132-133면; 이주헌, "도산절차상 가산금의 지위", 『사법』 제1권 제46호, 2018, 86-90면.

4) 주진암, "도산절차에서 가산금·중가산금의 지위", 『법조』 제57권 제10호, 2008, 149-158면.

5) 손홍수, "민사집행절차, 도산절차상 조세채권의 취급과 그 비교 검토", 『사법』 제1권 제49호, 2019, 79-82면.

www.kci.go.kr

입법정책상 재단채권으로 취급되었다는 사정만으로 파산선고 후 발생한 조세 부대채권까지 같은 지위를 부여할 수 없다고 분석한다.[7] 나아가 최성근은 도산절차에서 경제적 효율성과 이해관계인 간 형평성을 함께 고려하여야 한다고 보고, 조세채권의 우월적 지위가 채권자 사이의 배분적 정의에 미치는 영향을 비판적으로 검토하였다.[8]

이들 연구는 조세채권의 우월적 지위를 도산절차의 효율성과 채권자 간 형평이라는 관점에서 비판적으로 검토하였다는 점에서 의의를 가진다. 그러나 파산선고 후 발생하는 가산금·중가산금의 절차상 지위를 직접 다룬 선행연구는 종전의 가산금·중가산금 제도 또는 이후의 제도변화 이전 법체계를 전제로 한다. 납부지연가산세의 일별 납세의무 성립규정은 2019년 말 개정으로 이미 도입되었고, 2025년 12월 23일 개정은 지정납부기한 후의 기간경과분을 월별 산정·성립 구조로 전환하였다. 따라서 현행법에서는 세법상 각 기간분의 성립시기와 채무자회생법 제423조의 '원인' 사이의 관계뿐 아니라, 파산선고일 전후 또는 특례대상기간의 경계를 걸치는 월별 성립분을 도산법상 어떻게 귀속시킬 것인지까지 새로 검토할 필요가 있다.

본 글은 이러한 현행 성립구조 아래에서 파산선고 후 기간경과분의 파산채권 해당성, 배당순위 및 면책효를 구별하여 검토한다. 특히 세법이 각 기간분에 별도의 납세의무 성립시기를 부여하였다는 사실이 곧 각 기간분의 도산법상 '원인'도 그때마다 새로 발생한다는 것을 의미하는지는 별도로 판단하여야 한다. 이를 출발점으로 납부지연가산세의 파산절차상 채권 분류와 배당순위 및 면책효를 구분하여 검토한다.

구체적인 분석 대상은 파산선고 전에 성립한 본세가 미납된 상태에서 국세기본법 제47조의4 제1항 제1호 또는 제1호의2에 따라 파산선고

---

6) 이의영, "도산절차에서 조세채권의 지위(하)", 『법조』 제58권 제7호, 2009, 191-202면; 정지선/이기욱, "기업의 도산과 조세채권의 취급", 『법과정책연구』 제13권 제1호, 2013, 341-342면.

7) 임치용, "재단채권에 기한 이행소송과 강제집행은 가능한가", 『법조』 제54권 제12호, 2005, 74-78면.

8) 최성근, 『도산절차의 형평성 확보를 위한 법제개선방안』, 한국법제연구원 연구보고 04-11, 2004, 11-13면 및 39-44면.

www.kci.go.kr

후 기간의 경과만으로 성립하는 납부지연가산세이다. 3퍼센트의 정률분(제47조의4 제1항 제3호), 독촉비용(제47조의4 제1항 제4호), 신고의무 위반에 따른 가산세(제47조의2) 및 파산선고 후 성립한 본세는 분석대상에서 제외한다.[9] 본 글이 다루는 핵심 쟁점은 이와 같이 범위를 한정한 납부지연가산세를 파산절차에서 어떠한 채권으로 취급하고, 면책결정 후 채무자의 책임을 어느 범위까지 남길 것인지다.

분석은 현행법 해석과 입법론의 두 단계로 진행한다. 먼저 현행법 해석에서는 납부지연가산세의 세법상 성립시기와 채무자회생법 제423조가 규정한 파산채권의 원인 발생시를 구별한 다음, 가능한 네 가지 분류를 관련 조문의 문언과 체계 및 판례의 법리에 비추어 평가한다. 이어 입법론에서는 납부지연가산세의 성립시기, 파산절차상 배당순위 및 면책효를 상호 구별되는 규율요소로 파악하고, 각 방안이 조세수입의 확보, 일반채권자의 보호, 채무자의 통제가능성 및 제도의 집행비용에 미치는 영향을 비교한다. 이러한 접근은 후순위파산채권이라는 이유만으로 곧바로 면책대상이라고 보거나, 조세 부대채권이라는 이유만으로 그 법적 효과가 모두 본세에 종속된다고 보는 단선적인 결론을 피하기 위함이다.

파산절차는 개별채권자의 선착순 집행을 중단하고 파산재단을 공동으로 환가·배당하기 위한 절차이다.[10] 이러한 공동변제의 구조에서는 특정 채권에 우선권을 부여할수록 다른 채권자의 배당액이 감소한다. 이에 본 글은 각 부대채권이 파산절차의 공동비용에 해당하는지, 해당 부담의 증가에 관한 변제통제가 누구에게 귀속되어 있었는지, 우선변제가 다른 채권자의 배당과 면책 후 채무자의 재기에 어떠한 영향을 미

9) 이들 금액을 제외하는 것은 도산법상 보호가치의 차이 때문이 아니라 성립구조가 기간경과분과 다르기 때문이다. 3퍼센트 정률분은 지정납부기한의 경과라는 일회적 사실에 따라 성립하고, 신고의무 위반에 따른 가산세는 별도의 의무위반을 요건으로 한다. 이에 비하여 본 글이 다루는 기간경과분은 파산선고 전 성립한 본세의 미납을 전제로 선고 후 시간의 경과에 따라 계속 증가하므로, 분석대상을 이 경우에 한정한다. 국세기본법 제21조 제2항 제11호, 제47조의2 및 제47조의4 제1항 참조.

10) 김성용/오수근, "도산법에 대한 법경제학적 고찰",『법경제학연구』제8권 제1호, 2011, 125-130면.

www.kci.go.kr

치는지를 주요 판단기준으로 삼는다.

결국 논지는 파산선고 후 채무자가 파산재단에 속한 재산을 통한 본세의 변제 여부를 스스로 결정할 수 없는 기간에 대응하여 증가한 납부지연가산세에 본세와 동일한 우선성 및 비면책성을 부여할 것인지에 있다. 이에 본 글은 일별분과 월별분의 성립구조를 토대로 그 파산절차상 지위와 면책 여부를 규명하고, 각 해석이 일반채권자의 배당과 면책 후 채무자의 재기에 미치는 영향을 비교한다. 이를 통해 조세징수의 공익성을 존중하면서도 파산선고 후 발생분의 우선성과 비면책성이 인정되는 범위를 제시하고자 한다.

Ⅱ. 납부지연가산세의 성립구조와 파산절차상 지위

1. 납부지연가산세의 세법상 성립구조

(1) 일별 성립분과 월별 성립분

국세기본법 제21조 제2항 제11호 나목에 따르면 본 글의 분석대상인 제47조의4 제1항 제1호의 금액은 법정납부기한 경과 후 1일마다 성립하고, 다목에 따르면 제1호의2의 금액은 지정납부기한 경과 후 매 1개월이 경과할 때 성립한다. 반면 라목의 3퍼센트 정률분과 독촉비용은 지정납부기한 경과 시 성립한다.[11] 제1호는 법정납부기한 다음 날부터 납부고지일 또는 그 전에 납부한 경우 그 납부일의 전날까지의 기간을 일 단위로 산정하고, 제1호의2는 지정납부기한 다음 날부터 납부일 전날까지 경과한 개월 수를 기준으로 산정한다.

2025년 12월 23일 개정(2026년 7월 1일 시행)은 지정납부기한 후 납부지연가산세의 산정방식을 일 단위에서 월 단위로 전환하여 납세자의 계산 부담을 줄이고 납세편의를 높이려는 것이었다.[12] 다만 2026년 6

www.kci.go.kr

11) 국세기본법 제21조 제2항 제11호 나목 내지 라목 및 제47조의4 제1항.

월 30일 이전에 지정납부기한이 경과한 경우에는 국세기본법 부칙(2025. 12. 23. 법률 제21212호) 제2조 및 제3조에 따라 납부지연가산세의 납세의무 성립시기와 세액 계산에 종전 규정이 적용된다. 따라서 이하에서 설명하는 지정납부기한 후 월별 성립분에 관한 논의는 위 개정 규정이 적용되는 경우를 전제로 한다. 일별분은 각 날이 경과할 때마다 납세의무가 성립하므로 파산선고 전·후의 성립분을 일 단위로 식별할 수 있다. 반면 월별분은 하나의 1개월 산정기간이 파산선고일 전후에 걸칠 수 있고, 세법상 납세의무는 그 1개월이 경과하는 때 해당 월분에 대하여 성립한다. 따라서 세법상 성립시기만 따르면 그 월분 전체가 파산선고 후 성립한 것으로 평가될 수 있으나, 그 가운데 파산선고 후의 기간에 대응하는 부분만을 채무자회생법상 별도로 귀속시킬 것인지는 별개의 문제이다.

(2) 법적 성질과 분석범위

납부지연가산세는 국세기본법 제47조 제2항에 따라 해당 국세 세목으로 취급된다.[13] 그러나 본 글이 다루는 제47조의4 제1항 제1호와 제1호의2의 금액은 미납세액과 경과기간 또는 경과 개월 수를 기초로 산정되고, 적용 이율도 금융회사의 연체대출금 이자율 등을 고려하여 정해지므로, 적어도 그 산정구조상 납부지연에 대응하는 지연보전적 기능이 강하다. 따라서 세법상 해당 국세의 세목으로 취급된다는 사정만으로 본세와 동일한 도산법상 지위가 곧바로 정해진다고 볼 수 없고, 면책 여부 역시 별도로 검토하여야 한다.[14] 특히 파산선고 후 기간경과

12) 국회예산정책처, 『2025년 개정세법 심의 결과 및 주요 내용』, 2025, 115-116면.

13) 국세기본법 제47조 제2항.

14) 국세기본법 제47조의4 제1항 제1호·제1호의2는 미납세액과 경과기간 또는 경과 개월 수 및 금융회사의 연체대출금 이자율 등을 고려한 이율을 기초로 금액을 산정한다. 부대채권의 세법상 본세와의 관계와 도산절차상 지위는 구별하여 검토할 필요가 있다. 대법원 2017. 11. 29. 선고 2015다216444 판결도 구 가산금·중가산금에 관하여 본세가 재단채권이라는 이유만으로 선고 후 발생분까지 같은 지위를 갖는다고 보지 않았다. 반대로 본세와 부대채권의 종속성 및 파산관재인의 불납부를 중시하여 재단채권성을 인정하는 견해로는 주진

분은 기존의 미납상태를 전제로 하면서, 선고 후 새로운 신고누락이나 그 밖의 별도 행위가 추가되지 않더라도 시간의 경과에 따라 일별 또는 월별로 성립한다. 이러한 기간비례적 구조는 지정납부기한의 경과를 기준으로 정률로 한 번 산정되는 제3호의 금액, 독촉에 실제로 드는 비용인 제4호의 금액, 그리고 신고의무 등 별도의 세법상 의무위반을 요건으로 하는 다른 가산세와 구별된다.

따라서 본 글의 분석대상은 본세 자체나 파산선고 전까지 성립한 납부지연가산세가 아니라, 파산선고 전 성립한 본세의 미납을 전제로 선고 후 시간의 경과에 따라 성립하는 제1호 및 제1호의2의 금액으로 한정한다. 이러한 구분은 본세와 선고 전 성립분의 법적 지위를 변경하려는 것이 아니라, 선고 후 기간경과분의 절차상 지위와 면책 여부를 별도로 검토하기 위한 분석상의 구분이다.

2. 파산절차상 지위의 해석

(1) 판례의 도달점

대법원 2017. 11. 29. 선고 2015다216444 판결은 채무자회생법 제473조 제2호가 파산선고 전의 원인으로 인한 국세·지방세 등의 청구권을 재단채권으로 정하면서도, 그중 제446조에 따른 후순위파산채권은 명시적으로 제외하고 있다는 점에서 출발하였다. 이어 구 국세징수법상 가산금·중가산금은 납세의무의 이행지체에 대하여 부담하는 지연배상금의 성질을 가지므로, 파산선고 전의 원인으로 인한 국세·지방세에 기하여 선고 후 발생한 부분은 제446조 제1항 제2호의 '파산선고 후의 불이행으로 인한 손해배상액'에 해당한다고 보았다. 따라서 본세가 재단채권에 해당하더라도 그에 기하여 파산선고 후 발생한 가산금·중가산금은 후순위파산채권으로서 재단채권에서 제외된다.[15]

또한 대법원은 파산관재인의 직무상 불이행으로 가산금이 발생하였

암, 앞의 논문(주 4), 149-158면 참조.

15) 대법원 2017. 11. 29. 선고 2015다216444 판결, 판결요지 [1].

www.kci.go.kr

더라도 조세채권에 관한 제473조 제2호가 관재인의 행위로 인한 청구권에 관한 제4호보다 우선 적용된다고 보았다. 다만 이 판결의 직접 대상은 구 가산금·중가산금이었고, 이후 이루어진 납부지연가산세 체계로의 개편이나 2025년 개정에 따른 일별·월별 납세의무 성립구조는 판단대상이 아니었다.

이 판결이 현행 납부지연가산세에 주는 의미는 두 층위로 나누어 보아야 한다. 첫째, 본세의 미납에 부수하여 시간의 경과에 따라 산정되는 금액을 본세와 구별하고 그 지연보전적 기능을 중시한 판결의 관점은 현행 제1호와 제1호의2를 해석하는 데에도 참고할 수 있다. 다만 그 판결의 결론까지 현행법에 그대로 적용할 수 있는 것은 아니다. 여기에 두 번째 층위로서, 현행 국세기본법은 해당 기간경과분에 대하여 일별 또는 월별로 별도의 납세의무 성립시기를 정하고 있으므로 먼저 선고 후 기간경과분이 제423조의 '파산선고 전의 원인으로 생긴 청구권'에 해당하는지를 판단하고, 이를 긍정한 경우에 비로소 제446조에 따른 후순위 여부를 검토하여야 한다.

요컨대 2015다216444 판결은 현행 기간경과분의 후순위파산채권성을 뒷받침할 중요한 논거를 제공하지만, 그 결론을 현행 납부지연가산세에 직접 적용할 수 있는지는 제423조의 '원인'에 관한 별도의 검토를 요한다.[16]

(2) 네 가지 해석 가능성

채무자회생법 제423조는 파산채권의 범위를, 제446조는 파산채권 상

16) 강상우는 2015다216444 판결의 지연배상금 논리를 당시 개정된 납부지연가산세에도 적용할 수 있다고 보았다. 이주헌 역시 종전 가산금·중가산금에 관하여 그 지연배상적 성격과 제473조 제2호의 문언을 근거로 후순위파산채권설을 지지하였다. 다만 위 연구들이 전제로 한 법체계 이후에는 2019년 말 일별 납세의무 성립규정의 도입과 2025년 지정납부기한 후 월별 산정·성립 구조로의 전환이 이루어졌다. 따라서 현행법에 관하여는 위 연구들의 지연보전적 기능 및 제446조·제473조의 체계에 관한 논거를 참고하되, 각 기간분의 세법상 성립시기와 제423조의 원인 판단 사이의 관계를 별도로 검토할 필요가 있다. 강상우, 앞의 논문(주 3), 132-133면; 이주헌, 앞의 논문(주 3), 86-90면.

호간의 변제순위를 각각 정한다. 제473조는 재단채권의 범위를 정하고, 제475조는 재단채권을 파산절차에 의하지 아니하고 수시로 변제하도록 한다. 제566조는 면책결정 확정 후 파산채권에 대한 채무자의 책임이 면제되는 범위와 그 예외를 규율한다.[17] 따라서 특정 청구권의 파산채권 해당성, 파산절차 내 순위, 재단채권 해당성 및 면책효는 서로 구별하여 검토하여야 하며, 어느 한 단계의 결론만으로 다른 단계의 결론이 당연히 도출되는 것은 아니다.

제423조의 '파산선고 전의 원인으로 생긴 청구권'은 파산선고 당시 청구권의 내용이 구체적으로 확정되거나 변제기가 도래하였을 것까지 요구하지 않는다. 청구권의 주요한 발생원인이 파산선고 전에 갖추어져 있으면 족하므로 조건부채권이나 장래청구권도 파산채권에 포함될 수 있지만, 청구권 발생에 대한 단순한 기대에 그치는 경우에는 그렇지 않다.[18][19] 이 사안의 쟁점은 파산선고 전 본세의 성립, 납부기한의 경과 및 미납이 선고 후 기간경과분의 주요한 발생원인으로 평가될 수 있는지에 있다.

1) 후순위파산채권설

후순위파산채권설은 파산선고 전 본세의 성립, 납부기한의 경과 및 미납이 선고 후 기간경과분의 주요한 발생원인을 이룬다고 본다. 이에 따르면 기간경과분은 제423조의 파산채권에 해당하고, 그 지연보전적

17) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제423조, 제446조, 제473조, 제475조 및 제566조; 서울회생법원, 『개인파산관재인 직무편람』 제4판, 2024, 25-26면, 77-78면.

18) 전대규, 『채무자회생법』 제10판 제2권, 법문사, 2026, 1569-1574면; 노영보, 『도산법강의』 제2판, 박영사, 2024, 228-237면; 전병서, 『도산법』 제5판, 박영사, 2024, 143-145면; 정현수, 「제423조」, 『주석 채무자회생법』 제2판 제4권, 한국사법행정학회, 2025, 13-14면; 대법원 2012. 11. 29. 선고 2011다84335 판결.

19) 제423조의 '원인'과 세법상 납세의무의 성립시기는 동일한 판단기준이 아니다. 국세기본법 제21조는 조세채권 자체가 언제 성립하는지를 정하는 반면, 채무자회생법 제423조는 해당 재산상 청구권을 파산절차에 편입할 수 있는지가 파산선고 전의 원인과 연결되는지를 정한다. 따라서 세법상 성립시기를 무시할 수 있다는 의미가 아니라, 파산선고 전 본세의 성립·납부기한 경과·미납이 선고 후 기간경과분의 주요한 발생원인에 해당하는지를 제423조에 따라 별도로 판단하여야 한다는 의미이다.

www.kci.go.kr

기능에 비추어 제446조 제1항 제2호의 후순위파산채권으로 분류된다. 이는 파산선고 후의 이자와 불이행손해를 후순위로 둔 제446조의 취지 및 구 가산금에 관한 대법원 2017. 11. 29. 선고 2015다216444 판결의 논거와 궤를 같이한다.[20] 다만 현행 국세기본법이 기간경과분의 납세의무를 일별·월별로 성립시키는 점을 제423조의 '파산선고 전의 원인' 인지의 판단과 어떻게 조화시킬지의 문제는 해결되지 못한다.

2) 비파산채권설

비파산채권설은 국세기본법 제21조가 파산선고 후의 기간경과분에 대하여 일별 또는 월별로 별개의 납세의무 성립시기를 정하고 있다는 점에서 출발한다. 세법상 해당 조세채권이 파산선고 후 비로소 성립한다면 그 청구권의 발생원인 역시 파산선고 후에 존재한다고 보아, 제423조의 '파산선고 전의 원인으로 생긴 청구권'에 해당하지 않는다고 해석할 수 있다. 이 견해는 국세기본법 제21조의 별도 성립시기를 가장 직접적으로 반영한다는 장점이 있다. 대법원도 파산선고 후 발생한 조세채권 중 재단채권에 해당하지 않는 것은 '파산채권도 아니고 재단채권도 아닌 조세채권'에 해당할 수 있음을 인정하고 있다.[21]

다만 위 판결에서 이러한 법리가 적용된 것은 본세 자체가 파산선고 후 발생한 조세채권이었으므로, 파산선고 전 성립한 본세의 미납을 전제로 선고 후 시간의 경과에 따라 성립하는 기간경과분과는 구조가 다르다. 또한 비파산채권설은 세법상 납세의무의 성립시기와 제423조의

20) 강상우, 앞의 논문(주 3), 125-127면 및 132-133면; 정현수, 「제446조」, 『주석 채무자회생법』 제2판 제4권, 한국사법행정학회, 2025, 93-94면; 전선주, 「제473조」, 『주석 채무자회생법』 제2판 제4권, 한국사법행정학회, 2025, 301-302면. 다만 전선주는 파산선고일 이후의 납부지연가산세를 후순위파산채권으로 분류하면서도, 2025년 개정에 따른 월별 성립구조와 제423조의 관계를 별도로 논증하고 있지는 않다.

21) 대법원 2017. 11. 29. 선고 2015다216444 판결, 판결요지 [2]. 위 판결은 파산선고 후 발생한 조세채권 중 재단채권에 해당하지 않는 조세채권을 '파산채권도 아니고 재단채권도 아닌 조세채권'으로 보았다. 다만 위 법리가 적용된 '순번 5의 부가가치세 및 가산금'은 본세 자체가 파산선고 후 발생한 사안이므로, 파산선고 전 성립한 본세에 기하여 선고 후 성립하는 현행 납부지연가산세에 그 결론이 직접 적용된다고 볼 수는 없다.

www.kci.go.kr

‘원인’을 사실상 동일한 기준으로 파악한다는 점에서, 파산선고 전에 이미 형성된 본세의 성립・납부기한 경과・미납을 기간경과분의 주요한 발생원인으로 볼 수 있는지를 별도로 설명하여야 한다. 이 견해를 취하면 해당 금액은 파산절차의 배당대상에서 제외되고 제566조 본문의 면책효도 미치지 않으므로, 절차 종료 후에도 채무자의 개인책임으로 존속한다. 이 경우 책임이 면제되지 않는 이유는 제566조 단서 제1호의 조세 비면책 규정 때문이 아니라, 애초에 제566조 본문의 적용대상인 파산채권에 해당하지 않기 때문이다.

3) 재단채권설

재단채권설은 본세와 부대채권의 종속성 및 재단채권인 본세의 실효적 보호를 중시하여 선고 후 증가분도 재단채권으로 보거나, 관재인이 수시변제 대상인 본세를 변제하지 않은 부작위에 기하여 발생한 청구권으로서 제473조 제4호의 재단채권에 해당한다고 본다.[22] 이 견해는 본세와 그 미납에 부수하여 발생하는 부담의 절차상 지위를 일관되게 유지할 수 있다는 장점이 있다.

다만 선고 후 기간경과분까지 재단채권으로 인정하면 그 금액은 일반 파산채권에 우선하여 수시로 변제되므로 일반 파산채권자의 공동변제재원이 그만큼 감소한다. 또한 구 가산금・중가산금에 관하여 대법원은 조세 관련 청구권에 관한 제473조 제2호가 관재인의 행위로 인한 청구권에 관한 제4호보다 우선 적용된다고 보았고, 파산선고 후 발생한 가산금・중가산금을 제446조 제1항 제2호의 후순위파산채권으로 보아 재단채권성을 부정하였다. 따라서 현행 납부지연가산세의 기간경과분을 다시 제473조 제4호의 재단채권으로 평가하려면, 현행 제도의 성립구조가 위 판례와 달리 취급할 정도의 근거가 되는지를 별도로 제시할 필요가 있다.

---

22) 주진암, 앞의 논문(주 4), 149-158면. 특히 149-151면은 파산관재인이 재단채권인 본세를 변제하지 않은 부작위가 제473조 제4호의 ‘파산재단에 관하여 파산관재인이 한 행위’에 해당한다고 본다. 이에 대하여 대법원 2017. 11. 29. 선고 2015다216444 판결은 구 가산금・중가산금에 관하여 제473조 제2호가 제4호보다 우선 적용된다고 보아 재단채권성을 부정하였다.

4) 관재인 귀책을 고려한 제한적 구성

파산재단에 본세를 변제할 충분한 재원이 있었음에도 파산관재인이 정당한 사유 없이 변제를 지체하여 기간경과분이 증가한 경우에는 그 증가분을 일반적인 경우와 달리 취급할 수 있는지가 문제될 수 있다. 이러한 구성은 증가한 부담과 그 발생에 대한 통제를 대응시킬 수 있다는 점에서 직관적 설득력이 있다. 다만 관재인의 귀책이나 재단의 변제가능성은 원칙적으로 관재인의 이행지체책임이 성립하는지를 판단하는 사정이지, 기간경과분 자체의 발생원인이나 채권의 법적 성질을 변경하는 사정이라고 보기는 어렵다.[23]

특히 동일한 납부지연가산세의 절차상 지위가 재단의 자력이나 관재인의 개별적 판단에 따라 달라진다면 채권분류가 채권 발생 후의 우연한 사정에 좌우되어 법적 예측가능성이 저해될 수 있다. 따라서 관재인의 귀책이 문제되는 경우에도 기간경과분 자체의 절차상 지위는 그 발생원인과 법률의 규정에 따라 객관적으로 정하고, 관재인의 부당한 변제지체로 별도의 손해가 발생하였는지는 그와 구별하여 검토하는 것이 타당하다.

앞의 논의를 종합하면, 기간경과분의 절차상 지위는 다음과 같은 순서로 판단할 필요가 있다. 먼저 기간경과분이 제423조의 '파산선고 전의 원인으로 생긴 청구권'에 해당하는지를 판단하여야 한다. 이를 긍정하면 기간경과분은 파산채권이 되고, 그 다음 제446조에 따라 파산채권 상호간의 순위를 정하여야 한다. 기간경과분이 제446조 제1항 제2호의 후순위파산채권에 해당한다면 제473조 제2호에 따라 재단채권에서는 제외된다. 반대로 제423조의 파산채권성을 부정하는 경우에는 파

23) 재단채권의 변제지체와 관련하여 대법원 2014. 11. 20. 선고 2013다64908 전원합의체 판결은 파산관재인이 재단채권인 임금 등의 변제를 지체하여 발생한 손해배상청구권을 제473조 제4호의 재단채권으로 보았다. 다만 이는 기존 재단채권 자체의 성질을 관재인의 귀책에 따라 변경한 것이 아니라, 관재인의 이행지체로 별도로 발생한 손해배상청구권의 지위를 판단한 것이다. 조세에 관하여는 대법원 2017. 11. 29. 선고 2015다216444 판결이 제473조 제2호를 제4호에 대한 특별규정으로 보았다는 점에서 구분할 필요가 있다.

산선고 후의 원인으로 생긴 조세채권으로서 파산재단에 관하여 생긴 것인지 제473조 제2호 단서에 따라 별도로 판단하여야 하고, 이 요건도 충족하지 못하면 파산채권도 재단채권도 아닌 조세채권으로 남게 된다. 관재인의 귀책이나 재단의 변제가능성은 이러한 채권분류와 별개로 관재인의 이행지체책임 또는 비용부담 여부를 판단하는 문제로 다루는 것이 타당하다.

이러한 판단구조에서 보면 후순위파산채권설은 파산선고 전 본세와 선고 후 기간경과분의 연속성, 제446조 제1항 제2호의 기능 및 제473조 제2호의 후순위파산채권 제외구조를 함께 설명할 수 있다는 점에서 가장 높은 설명력을 가진다. 다만 국세기본법 제21조가 기간경과분에 대하여 일별·월별로 별도의 납세의무 성립시기를 정하고 있는 이상, 파산선고 전 본세의 성립·납부기한 경과·미납을 선고 후 기간경과분의 제423조상 '원인'으로 평가할 수 있는지는 별도의 논증을 필요로 한다.

3. 후순위파산채권설의 타당성

기간경과분을 후순위파산채권으로 보기 위해서는 먼저 그 청구권이 제423조의 파산채권에 해당하여야 한다. 앞서 본 바와 같이 제423조의 '파산선고 전의 원인으로 생긴 청구권'은 파산선고 당시 청구권의 내용이 구체적으로 확정되거나 변제기가 도래하였을 것까지 요구하지 않고, 청구권의 주요한 발생원인이 선고 전에 갖추어져 있으면 족하다. 따라서 이 사안에서는 기간경과분의 세법상 납세의무가 선고 후 성립한다는 사실만으로 판단을 끝낼 것이 아니라, 파산선고 전에 이미 성립한 본세와 그 납부기한의 경과 및 미납상태가 선고 후 기간경과분의 주요한 발생원인으로 평가될 수 있는지를 검토하여야 한다.

제446조 제1항 제2호의 해석은 이러한 판단 이후의 순위결정에 중요한 기준을 제공한다. 이 규정의 '파산선고 후의 불이행으로 인한 손해배상액 및 위약금'은 파산선고 후에 새로 발생한 불이행만을 의미하는 것이 아니라, 선고 전부터 존재하던 불이행이 계속되어 선고 후 발생하는 손해배상액 또는 위약금도 포함하는 것으로 해석된다.[24] 대법원도

www.kci.go.kr

구 회사정리법의 대응규정에 관하여, 절차개시 전부터 재산상 청구권의 불이행이 존재하고 그 계속으로 절차개시 후 손해배상액이나 위약금이 발생하는 경우 이를 후순위채권으로 취급하는 법리를 제시하였다. 따라서 제446조 제1항 제2호도 선고 전부터 존재한 기초채무의 불이행과 선고 후 계속 발생하는 부수채권을 연결하여 후순위화하는 규정으로 이해할 수 있다.

구 가산금·중가산금에 관한 대법원 2017. 11. 29. 선고 2015다216444 판결도 같은 구조에 있다.[25] 대법원은 파산선고 전의 원인으로 인한 조세에 기하여 선고 후 발생한 가산금·중가산금이 납세의무의 이행지체에 대한 지연배상금의 성질을 가진다는 이유로 제446조 제1항 제2호의 후순위파산채권에 해당한다고 판단하였다. 이는 파산선고 전 본세의 미납이라는 기초상태와 선고 후 기간의 경과에 따라 증가하는 부대채권의 관계를 제446조 제1항 제2호의 불이행손해 구조로 파악한 것이다.[26]

다만 이 법리를 현행 납부지연가산세에 그대로 적용할 수는 없다. 현행 국세기본법 제21조는 제47조의4 제1항 제1호 및 제1호의2의 금액에 대하여 각각 일별·월별로 별도의 납세의무 성립시기를 정하고 있기 때문이다. 이에 따르면 선고 후 기간경과분은 선고 후 비로소 성립한 조세채권이므로, 그 '원인' 역시 선고 후에 존재한다고 보아 제423조의 파산채권성을 부정하여야 한다는 반론이 가능하다.

그러나 이러한 반론이 곧바로 결론을 정하는 것은 아니다. 국세기본법 제21조가 정하는 것은 조세채권 자체의 법률상 성립시점인 반면, 제423조는 해당 재산상 청구권의 주요한 발생원인이 파산선고 전에 갖추어져 있는지를 기준으로 파산절차 편입 여부를 정한다. 이는 제423조의 원인 개념을 세법상 성립시기에 우선시키려는 것이 아니라, 서로 다

24) 정현수, 「제446조」, 『주석 채무자회생법』 제2판 제4권, 한국사법행정학회, 2025, 93-94면; 대법원 2004. 11. 12. 선고 2002다53865 판결.

25) 정현수, 앞의 책(주 20), 94면; 대법원 2017. 11. 29. 선고 2015다216444 판결.

26) 본세가 재단채권이라는 사정만으로 그 미납에 기하여 파산선고 후 발생하는 부대채권까지 당연히 재단채권의 지위를 가져야 하는 것은 아니라는 지적도 이와 같은 구별을 뒷받침한다. 임치용, 앞의 논문(주 7), 74-84면.

른 규율목적을 가진 두 기준을 각각 적용하여야 한다는 의미이다. 대상 기간경과분은 파산선고 전에 이미 성립하고 납부기한이 경과한 본세의 미납을 전제로 하며, 선고 후 새로운 신고누락이나 허위신고 등 별도의 행위를 요하지 않고 시간의 경과에 따라 산정된다. 따라서 세법상 선고 후 성립이라는 사정은 제423조의 원인을 판단할 때 중요한 고려요소이지만, 그것만으로 파산선고 전 본세의 성립·납부기한 경과·미납이 기간경과분의 주요한 발생원인이 될 가능성까지 배제한다고 보기는 어렵다.

이러한 발생구조, 제423조의 원인 개념, 제446조 제1항 제2호의 해석 및 2015다216444 판결의 법리적 관점을 종합하면, 국세기본법 제21조에 따른 반대해석의 가능성에도 불구하고 본 글은 파산선고 전 본세의 성립·납부기한 경과·미납을 선고 후 기간경과분의 주요한 발생원인으로 보아 이를 제423조의 파산채권에 편입하고, 그 지연보전적 기능에 따라 제446조 제1항 제2호의 후순위파산채권으로 분류하는 해석이 보다 타당하다고 본다.

기간경과분을 후순위로 분류하는 이유는 면책 여부와 구별된다. 이를 일반 파산채권과 같은 순위로 배당하면 파산절차가 장기화될수록 기간경과분이 증가하여 다른 파산채권자의 배당액을 감소시킬 수 있다. 반대로 재단채권으로 인정하면 일반 파산채권보다 먼저 변제되므로 공동변제재원을 더욱 크게 감소시킨다. 조세 부대채권에 재단채권 또는 이에 준하는 우월적 지위를 부여할 것인지는 그 채권이 절차관여자의 공동이익에 기여하는지와 일반채권자의 배당에 미치는 영향을 함께 고려하여 제한적으로 판단하여야 한다는 견해도 이러한 문제를 지적한다.[27] 기간경과분은 선고 전 본세에 결부된 지연보전적 부수채권이면서 선고 후 시간의 경과에 대응하여 증가하는 금액이므로, 이를 파산채권으로 신고·조사하되 일반 파산채권보다 뒤에서 배당하도록 하는 것이 발생원인과 배당형평을 함께 고려한 처리이다.

생각건대 관재인에게 본세의 변제지체에 관한 귀책이 있는 경우에도

27) 이의영, 앞의 논문(주 6), 191-202면; 정지선/이기욱, 앞의 논문(주 6), 328-334면 및 341면.

www.kci.go.kr

이러한 채권분류를 달리할 필요는 없다. 앞서 본 바와 같이 관재인의 귀책은 기간경과분 자체의 성립원인이나 법적 성질을 변경하는 사정이라기보다, 그로 인하여 별도의 이행지체책임 또는 비용부담이 성립하는지를 판단할 사정으로 보는 것이 타당하다. 따라서 기간경과분의 절차상 지위는 원칙적으로 그 발생원인과 법률의 규정에 따라 객관적으로 정하고, 관재인의 책임은 그 요건이 충족되는 경우 별도로 판단하여야 한다.

Ⅲ. 면책 한계와 입법적 조정의 필요성

1. 현행법상 면책구조의 한계

(1) 절차상 지위와 면책효의 구별

채무자회생법 제566조 본문의 면책효는 파산채권에 관한 채무자의 책임을 대상으로 한다. 따라서 선고 후 기간경과분의 절차상 지위를 어떻게 분류하는지에 따라 면책 여부에 이르는 법적 경로도 달라진다. 먼저 이를 비파산채권으로 보면 해당 청구권은 제423조의 파산채권에 해당하지 않으므로 제566조 본문의 면책효가 애초에 미치지 않는다. 재단채권으로 보는 경우에도 마찬가지로 제566조 본문에 따른 책임면제의 대상이 되지 않는다.[28] 이 경우 기간경과분이 면책되지 않는 이유는 조세에 관한 같은 조 단서 제1호가 적용되기 때문이라기보다, 우선 제566조 본문의 적용대상인 파산채권에 해당하지 않기 때문이다.

반면 기간경과분을 제446조 제1항 제2호의 후순위파산채권으로 보는 경우에는 논리구조가 다르다. 후순위파산채권도 파산채권이므로 제566조 본문의 적용대상에는 포함된다. 다만 그 채권이 같은 조 단서 제1호의 '조세'에 해당하면 책임면제에서 제외된다. 종전 가산금에 관한 하급심도 파산선고 후 발생한 가산금이 후순위파산채권에 해당한다는

28) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제566조 본문 및 단서 제1호.

www.kci.go.kr

점과 그것이 비면책채권인 '조세'에 해당한다는 점을 별개의 문제로 보아 양자를 모두 긍정하였다.[29] 따라서 후순위파산채권이라는 절차상 분류만으로 면책 여부가 결정되는 것은 아니다.

면책은 채무 자체를 소멸시키는 것이 아니라 채무자에 대한 이행강제 가능성을 제거하는 효력을 가진다. 따라서 면책된 채무에 관한 집행권원이 존재하는 경우 채무자는 청구이의의 소를 통하여 면책의 효력에 기한 집행력의 배제를 구할 수 있다. 파산절차에서 어떤 순위로 배당받는지와 절차 종료 후 채무자에게 이행을 청구할 수 있는지는 이처럼 서로 다른 문제이다.[30] 이처럼 채권의 절차상 지위와 면책 후 개인책임은 서로 다른 규율대상이므로, 입법적으로도 기간경과분의 절차상 편입·순위와 면책효를 분리하여 설계할 수 있다. 즉 채권의 성립과 절차상 지위를 유지하면서도 일정한 요건 아래 면책 후 개인책임만을 제한적으로 조정하는 방식이 가능하다.

(2) 조세 비면책에 관한 헌법재판소 결정의 범위

헌법재판소 2022. 9. 29. 선고 2019헌마874 결정은 조세채무를 면책대상에서 제외한 채무자회생법 제566조 단서 제1호가 조세채무자의 재산권을 침해하지 않는다고 판단하였다. 조세는 국가와 지방자치단체의 활동을 위한 재정적 기초이고, 조세채권까지 면책할 경우 조세면탈을 목적으로 한 파산신청으로 면책제도가 악용되거나 조세 부과·징수의 효율성과 실효성 및 재정수입 확보가 저해될 수 있다는 점이 그 근거였다.[31]

다만 위 결정이 판단한 것은 현행 제566조 단서 제1호가 파산채권인

29) 서울행정법원 2018. 8. 22. 선고 2018구단51488 판결; 서울고등법원 2019. 2. 8. 선고 2018누62241 판결.

30) 전대규, 앞의 책(주 18), 1802-1812면; 노영보, 앞의 책, 676-696면; 전병서, 앞의 책, 472-480면.

31) 특히 헌법재판소는 제566조의 면책효가 파산채권에 한정된다는 점을 전제로, 단서 제1호에 의하여 직접 면책에서 제외되는 조세는 원칙적으로 파산채권인 조세채권이고, 그 예로 파산선고 후 발생한 가산금채권 등을 들었다. 헌법재판소 2022. 9. 29. 선고 2019헌마874 결정, 결정이유 4.나.(1)·(2).

조세채권을 일률적으로 면책에서 제외하는 것이 헌법에 위반되는지 여부이다. 2025년 개정 이후 일별·월별로 별도의 납세의무가 성립하는 납부지연가산세 가운데 파산선고 후의 특정 기간에 대응하는 부분만을 대상으로 별도의 면책특례를 두는 입법의 허용 여부까지 판단한 것은 아니다. 요컨대 본세와 파산선고 전 성립분의 비면책을 유지하면서, 파산재단의 관리·처분권이 관재인에게 전속된 이후 채무자가 재단재산을 통한 본세의 변제 여부를 스스로 결정할 수 없었던 기간에 대응하는 금액만을 제한적으로 면책하도록 하는 입법이 위 결정에 의하여 곧바로 배제된다고 보기는 어렵다. 다만 이는 위 결정이 당시 법체계에서 파산선고 후 가산금채권의 비면책성을 인정한 점을 부정하는 것이 아니라, 이후의 제도변화와 채무자의 변제통제 가능성을 고려하여 입법자가 보다 좁은 예외를 설정할 수 있는지는 별도의 입법정책적·헌법적 문제라는 의미이다.[32]

2. 파산선고 후 증가분의 부담

(1) 재단관리·처분권의 전속과 채무자의 부담

파산재단에 속하는 재산의 관리·처분권은 파산관재인에게 전속한다.[33] 채무자는 본세 납부에 사용할 재단재산을 처분할 수 없지만, 본

32) 따라서 제한적 면책특례를 입법화한다면 헌법재판소가 제시한 조세징수의 확보와 면책제도 악용 방지라는 공익을 함께 고려하여 그 적용범위를 객관적으로 한정할 필요가 있다. 본 글은 이를 위하여 특례대상을 파산선고 후의 기간에 대응하는 일별·월별 성립분 중 법률이 정한 범위로 제한하고, 면책이 최종적으로 허용되지 않거나 그 면책이 취소된 경우 및 해당 기간경과분의 기초가 된 본세와 관련하여 법률이 정한 조세포탈죄의 유죄확정 등 객관적인 배제사유가 있는 경우에는 특별면책을 제한하는 방식을 제안한다. 이는 조세채권 일반의 면책을 허용하려는 것이 아니라, 헌법재판소가 인정한 조세 비면책의 공익적 근거를 유지하면서도 파산선고 후 변제통제의 귀속이 달라진 기간에 대응하는 부대부담만을 제한적으로 조정하려는 것이다. 헌법재판소 2022. 9. 29. 선고 2019헌마874 결정, 결정이유 4.나.(2).

33) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제384조.

www.kci.go.kr

세의 미납상태가 계속되는 동안 기간경과분은 일별 또는 월별로 계속 성립한다. 앞서 본 바와 같이 기간경과분을 후순위파산채권으로 보는 경우 그 순위상 실제 배당에 이를 가능성이 낮다. 그럼에도 해당 금액이 제566조 단서 제1호의 조세로서 비면책으로 남는다면, 파산절차에서 변제되지 않은 잔액에 관한 채무자의 개인책임은 면책 후에도 존속한다. 문제는 이처럼 파산절차 중 재단재산을 통한 본세의 변제에 관한 통제는 채무자에게 없으면서도, 그 기간에 대응하여 증가한 미변제액에 대한 책임은 다시 채무자에게 귀속될 수 있다는 데 있다.[34]

파산선고가 조세징수에 미치는 효과도 이러한 문제를 보여준다. 파산선고 전에 파산재단에 속하는 재산에 대하여 개시된 체납처분은 일정한 범위에서 속행될 수 있는 반면, 파산선고 후에는 파산재단에 속하는 재산에 대하여 새로운 체납처분을 할 수 없다.[35] 그러나 이러한 체납처분의 제한은 그 자체로 조세채권의 소멸이나 면책을 의미하지 않는다. 파산종결 또는 이시폐지로 재단재산의 관리·처분권이 채무자에게 돌아오면, 면책되지 않은 조세채권에 대해서는 다시 개별적인 강제징수가 가능해질 수 있다. 따라서 파산절차 중 체납처분을 제한하는 것만으로는 선고 후 기간경과분의 미변제잔액이 절차 후에도 채무자의 개인책임으로 남는 문제를 해소하기 어렵다.

이러한 점에서 입법적 조정의 핵심은 본세나 파산선고 전까지 성립한 납부지연가산세의 비면책성을 일반적으로 약화하는 데 있지 않다. 본 글은 그 비면책성을 유지하되, 파산선고 후 재단재산의 관리·처분권이 관재인에게 전속되어 채무자가 그 재산을 통한 본세의 변제를 스스로 통제할 수 없는 기간에 대응하는 증가분은 별도로 취급할 필요가 있다고 본다. 이러한 조정은 해당 증가분을 파산절차에 편입하여 후순위로 배당하면서도 일정한 요건 아래 미변제잔액에 대한 개인책임을 제한하는 방식으로 구체화할 수 있으며, 그 구체적인 대상기간과 면책

34) 이주헌, 앞의 논문(주 3), 82-83면 및 89-90면; 서울회생법원, 앞의 책(주 17), 77-78면.

35) 엄덕수, “파산절차가 민사집행 및 조세징수에 미치는 영향”, 『법무연구』 제9권, 2022, 235-244면.

www.kci.go.kr

배제사유는 Ⅳ에서 검토한다.

(2) 절차 종료 후 개인책임과 경제적 재기

앞서 본 바와 같이 후순위파산채권은 그 순위상 실제 배당에 이를 가능성이 낮다. 그럼에도 기간경과분이 비면책으로 남으면 파산절차에서 변제되지 않은 잔액은 절차 종료 후 채무자가 새로 취득한 소득·재산을 대상으로 한 징수의 대상이 될 수 있다. 이는 개인파산의 면책이 지향하는 경제적 재기와 긴장을 일으킬 수 있다.[36]

그렇다고 조세채권 일반을 면책하거나 파산선고 전까지 발생한 책임을 일률적으로 소멸시킬 필요가 있는 것은 아니다. 본세와 파산선고 전까지 성립한 기간경과분의 비면책성을 유지하면서, 파산선고 후 재단재산의 관리·처분권이 채무자에게 없었던 기간에 대응하는 미변제잔액만을 제한적으로 조정하는 방법을 검토할 수 있다. 다만 면책의 확대는 도덕적 해이나 제도악용의 가능성을 수반할 수 있으므로, 그 적용대상과 배제사유를 법률상 객관적으로 한정하여야 한다. 결국 입법적 과제는 기간경과분의 성립 자체를 제한할 것인지, 아니면 그 채권은 존속시키되 파산절차에 편입·후순위화하고 면책 후 개인책임만을 제한할 것인지를 선택하는 데 있다.

Ⅳ. 입법모델의 선택과 구체적 설계

1. 두 입법모델의 비교와 선택

(1) 세법상 발생정지형

제1안은 파산선고 후 법률이 정한 특례대상기간 동안 기간경과분의

www.kci.go.kr

36) 김성용/오수근, 앞의 논문(주 10), 160-164면.

세법상 납세의무가 성립하지 않도록 하는 방식이다. 특례대상기간을 법률에서 명확히 정하면 그 기간에 대응하는 금액은 애초에 조세채권으로 성립하지 않으므로, 해당 금액의 파산채권성·배당순위·면책 여부를 별도로 판단할 필요가 없다는 장점이 있다. 다만 월별 성립분의 경계기간을 어떻게 처리할 것인지에 관한 기술적 계산규정은 여전히 필요할 수 있다. 특례대상기간에 대응하여 애초에 성립하지 않은 금액에 대해서는 절차 종료 후 채무자의 신규재산을 대상으로 다시 징수하는 문제도 발생하지 않는다. 특히 기간경과분의 파산채권성·순위·면책효를 둘러싼 해석상 분쟁을 사전에 차단할 수 있다는 점이 발생정지형의 가장 분명한 장점이다.

반면 발생정지형은 면책제도와의 관계에서 설계상의 선택을 요구한다. 파산선고만을 기준으로 모든 개인파산사건에 발생정지의 효과를 부여한다면 면책불허가나 면책취소가 있더라도 정지기간의 국가채권은 발생하지 않게 된다. 이 방식은 구조가 단순하지만, 최종적으로 면책받지 못하는 채무자에게까지 국가채권 감소의 이익이 귀속된다는 문제가 있다. 반대로 발생정지의 이익을 최종적으로 면책받은 채무자에게만 한정하려면, 면책 여부가 확정될 때까지 해당 기간의 가상 발생액을 계산·관리하고, 면책불허가 또는 면책취소가 있는 경우 정지기간에 대응하는 금액을 사후적으로 성립시키거나 특례의 적용을 배제하는 별도의 규율이 필요하다. 결국 발생정지형은 무조건적으로 적용하면 조정범위가 지나치게 넓어지고, 면책결과와 연계하면 세액의 확정시기와 면책심사의 결과를 사후적으로 결부시키는 복잡성이 생긴다.[37]

또한 발생정지형에서는 파산재단에 잉여가 있는 사건에서도 국가가 특례대상 기간경과분에 관하여 배당받을 수 없고, 이를 실현하려면 국세기본법 제21조와 제47조의4 등 조세채권의 성립·산정규정 자체에 특례를 두어야 한다. 따라서 발생정지형은 기간경과분에 관한 채권분류와 면책 문제를 원천적으로 제거한다는 장점이 있지만, 무조건적 설계에서는 국가채권의 감소범위가 넓고 면책연계형 설계에서는 사후적 채권성립·정산구조가 필요하다는 한계가 있다. 채권 자체를 유지하면

37) 국세기본법 제21조 제2항 제11호, 제47조의4 제1항.

www.kci.go.kr

서 파산절차상 순위와 면책 후 개인책임만을 조정하는 방식에 비하여 규율범위가 넓다는 점도 고려할 필요가 있다.

(2) 절차편입・후순위화・제한적 면책형

제2안은 기간경과분의 세법상 성립은 유지하되, 파산선고 후의 특례대상분을 법률상 파산채권으로 편입하여 후순위에 배치하고, 일정한 요건을 충족한 면책채무자에 대해서는 그 미변제잔액에 관한 개인책임만을 제한하는 방식이다. 일반 파산채권을 만족시키고도 배당재원이 남는 경우 국가도 후순위채권자로서 기간경과분에 관한 배당을 받을 수 있는 반면, 일반 파산채권자의 배당순위는 그보다 앞선다. 면책이 최종적으로 인정되지 않거나 그 효력이 취소되는 경우, 또는 법률이 정한 면책배제사유가 있는 경우에는 기간경과분에 관한 개인책임을 존속시킬 수 있다. 따라서 국가채권 자체를 처음부터 발생시키지 않는 방식에 비하여 조정의 범위가 좁다.

제2안에서는 면책 여부가 확정되기 전에도 조세채권의 성립과 파산절차상 지위를 확정할 수 있고, 최종적으로 면책효가 인정되는 경우에만 미변제잔액에 관한 개인책임을 제한한다. 따라서 발생정지의 효과를 면책결과와 연계하는 제1안과 달리, 면책불허가나 면책취소에 대비하여 과거의 정지기간에 대응하는 국가채권을 사후적으로 성립시키거나 특례의 적용을 소급하여 배제하는 별도의 규율을 둘 필요가 없다. 또한 제423조의 파산채권 편입, 제446조의 배당순위, 제566조의 면책효라는 현행 채무자회생법의 규율단계를 그대로 활용할 수 있다는 점에서도 기존 파산법 체계와의 접합성이 높다.

두 방안은 규율의 명확성, 국가채권 제한의 범위, 일반 파산채권자의 배당보호, 기존 면책심사와의 연계 및 사후정산의 필요성을 기준으로 비교할 수 있다. 발생정지형은 기간경과분에 관한 채권분류와 면책 문제를 원천적으로 제거할 수 있지만, 무조건적으로 적용하면 국가채권의 감소범위가 넓고 면책결과와 연계하면 사후적인 채권성립・정산규율이 필요하다. 반면 제2안은 제423조・제446조・제566조를 연계하여

www.kci.go.kr

개정하여야 하므로 조문구조는 더 복합적이지만, 각 규정이 절차편입·배당순위·면책효라는 서로 다른 기능을 담당하도록 하여 채권 자체의 성립을 유지하면서 필요한 범위에서만 법적 효과를 조정할 수 있다. 기존의 면책결정 및 취소절차와 연계할 수 있다는 점도 장점이다.

이러한 점을 종합하면 제2안은 발생정지형보다 입법구조는 복합적이지만, 국가채권의 성립과 파산절차상 배당가능성을 보존하면서 일반 파산채권자의 배당을 보호하고, 최종적으로 면책이 인정되는 경우에만 개인책임을 제한할 수 있다는 점에서 본 글의 문제의식에 더 적합하다.

2. 핵심 조문의 연계와 제473조의 확인적 정비

후술할 입법안 예시는 개인파산에서의 면책 후 책임조정을 문제의 출발점으로 삼고 있으므로, 이러한 파산채권 편입 및 후순위화 특례도 개인인 채무자의 파산절차에 한정한다. 법인파산에서도 같은 채권분류를 적용할 것인지는 별도의 배당정책적 검토를 요하므로 본고의 범위에서 제외한다. 앞서 선택한 절차편입·후순위화·제한적 면책형을 실현하기 위해서는 기간경과분의 파산채권 편입, 그 배당순위 및 면책 후 개인책임을 서로 구별하여 규율할 필요가 있다. 먼저 제423조에는 파산선고 전에 본세가 성립하고 그 납부기한이 경과하였으나 미납된 경우, 「국세기본법」 제47조의4 제1항 제1호 또는 제1호의2에 따라 산정되는 금액 중 파산선고 후의 특례대상기간에 대응하는 부분을 파산채권으로 보는 특칙을 둘 필요가 있다. 이는 현행 국세기본법이 각 기간분에 별도의 납세의무 성립시기를 정함으로써 발생하는 제423조상 파산채권성의 불확실성을 입법적으로 해소하기 위한 것이다. 제446조에는 이와 같이 파산채권으로 편입된 기간경과분을 일반 파산채권보다 후순위로 정하는 별도의 규정을 두어야 한다. 제423조의 특칙이 절차편입 여부를 정한다면, 제446조의 특칙은 편입된 채권의 배당순위를 정한다. 이처럼 먼저 파산절차에 편입되는 청구권의 범위를 명확히 한 다음 그 순위를 별도로 정하는 방식은 채권의 절차상 편입과 순위결정을 단계적으로 구별한다는 점에서도 체계적이다.[38]

www.kci.go.kr

제473조의 경우에는 사정이 다르다. 현행 제473조 제2호는 국세징수법 또는 지방세징수법에 따라 징수할 수 있는 청구권을 재단채권으로 정하면서도 제446조에 따른 후순위파산채권을 그 범위에서 명시적으로 제외하고 있다. 따라서 제423조에서 기간경과분의 파산채권성을 명확히 하고 제446조에서 이를 후순위파산채권으로 규정한다면, 현행 제473조 제2호만으로도 해당 기간경과분은 재단채권에서 제외된다. 대법원 2017. 11. 29. 선고 2015다216444 판결 역시 제473조 제2호의 괄호규정이 제446조에 따른 후순위파산채권을 재단채권에서 제외하기 위한 것이라고 해석하였다. 그러므로 제473조는 제2안을 실현하기 위한 필수적 개정대상이 아니다. 다만 기간경과분의 재단채권성을 둘러싼 해석상 혼선을 차단할 필요가 있다면, 현행 법률효과를 변경하지 않는 범위에서 확인적 문언을 추가하는 방안은 검토할 수 있다.[39]

마지막으로 제566조에는 기간경과분에 관한 제한적 면책의 효과를 직접 규정하여야 한다. 제423조와 제446조의 개정만으로는 해당 채권이 파산절차에 편입되어 후순위로 배당된다는 점만 정해질 뿐, 면책 후 채무자의 개인책임까지 제한되지는 않는다. 현행 제566조 단서 제1호가 조세를 비면책채권으로 정하고 있으므로, 기간경과분의 미변제잔액에 한하여 책임을 제한하려면 제566조에 해당 후순위파산채권에 관한 명문의 면책특례를 둘 필요가 있다.[40]

3. 특례의 대상・기간・귀속 및 계산

입법상 특례대상은「국세기본법」제47조의4 제1항 제1호 및 제1호의2에 따른 납부지연가산세 중 파산선고 후의 특례대상기간에 대응하는 부분으로 직접 특정할 필요가 있다. 본세, 파산선고 전의 기간에 대응하는 부분, 같은 항 제3호의 3퍼센트 정률분, 제4호의 독촉비용 및 신고의무 위반 등 기간경과 자체와 다른 요건에 따라 성립하는 가산세는 대

38) 전대규, 앞의 책(주 18), 1587면 각주 59.
39) 대법원 2017. 11. 29. 선고 2015다216444 판결.
40) 국세기본법 제47조 제2항; 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제566조 단서 제1호.

www.kci.go.kr

상에서 제외한다. 또한 제1호의2에 관한 특례는 같은 조 제7항의 기간 한도와 제8항의 적용제외 등 현행 세법상 납부지연가산세가 실제 성립하는 범위 안에서만 적용된다.

제1호의 일별 성립분은 일 단위로 구분할 수 있으므로, 본 글은 파산선고 당일을 일할하지 않고 그 다음 날부터 특례대상기간에 산입하는 방식을 제안한다. 이는 파산선고일 중 선고 전·후의 시간을 별도로 계산하지 않으면서 귀속기준을 객관화하기 위한 것이다. 반면 제1호의2의 월별 성립분은 지정납부기한 후 매 1개월이 경과할 때 하나의 납세의무가 성립하므로, 그 1개월 산정기간이 특례대상기간의 시작 또는 종료시점을 걸치는 경우 세법상 성립시기만으로 해당 금액을 기간별로 구분할 수 없다.

따라서 제1호의2의 경우에는 세법상 납세의무의 성립방식 자체를 변경하기보다, 이미 세법에 따라 성립한 월별 금액 가운데 어느 부분을 채무자회생법상 특례대상기간에 귀속시킬 것인지를 정하는 특별규정을 두는 것이 타당하다. 구체적으로는 세법에 따라 성립한 해당 월별 금액에 그 1개월 산정기간의 총일수 중 특례대상기간과 중첩되는 일수가 차지하는 비율을 곱하여 특례대상액을 산정하는 일할안분방식을 취할 수 있다. 이는 하나의 월별 납세의무를 세법상 다시 분할하여 성립시키는 것이 아니라, 이미 성립한 금액을 도산법상 기간에 따라 귀속시키는 특칙이다. 파산선고일의 다음 날부터 적용한다는 기준과 월별분을 일할안분한다는 원칙은 법률에서 직접 정하고, 일수의 산정과 단수처리 등 기술적인 사항은 대통령령에 위임할 수 있다.

산정기간 중 본세의 일부납부가 있는 경우에도 미납세액의 변동에 따른 일별·월별 납부지연가산세의 성립액은 먼저 국세기본법에 따라 확정하고, 그와 같이 성립한 금액에 대하여 위 도산법상 귀속기준을 적용하는 것이 타당하다. 따라서 도산법상 특례가 세법상 미납세액이나 납세의무의 성립액 자체를 다시 계산하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 제1호와 제1호의2의 산정구간 역시 국세기본법이 정한 기산점과 종점을 그대로 전제로 한다.

특례대상기간의 종기는 그 제도의 근거가 되는 재단재산에 대한 변

www.kci.go.kr

제통제의 귀속과 일치시킬 필요가 있다. 따라서 본 글은 특례대상기간을 파산선고일의 다음 날부터 파산절차가 종결되거나 폐지되어 파산재단에 관한 채무자의 관리·처분권 제한이 종료되는 날의 전날까지로 정하는 방안을 제안한다. 이 기준은 하루 전체가 파산관재인의 재단관리 아래 있었던 기간만을 특례대상으로 한다는 점에서 시작일과 종료일을 대칭적으로 처리할 수 있다. 파산선고와 동시에 폐지되는 사건에서는 별도의 특례대상기간이 발생하지 않는다. 면책결정의 확정은 이 기간의 종기가 아니라, 특례대상 기간경과분 가운데 미변제잔액에 대한 책임을 실제로 면제하기 위한 별도의 요건으로 기능한다. 파산절차에서 해당 기간경과분에 관하여 배당 또는 변제가 이루어진 경우에는 그로써 소멸하지 않은 잔액에 대해서만 제한적 면책효가 미친다.[41]

4. 면책배제사유·지방세·경과규정

제한적 면책특례는 일반적인 면책이 최종적으로 허가된 채무자에게만 적용되는 것으로 설계하여야 한다. 면책이 허가되지 않은 경우에는 애초 제566조의 책임면제효가 발생하지 않으므로 이를 별도의 특례배제사유로 정할 필요가 없다. 또한 제564조 제2항은 면책불허가사유가 존재하는 경우에도 법원이 제반 사정을 고려하여 면책을 허가할 수 있도록 하고 있으므로, 면책불허가사유의 존재 자체를 다시 기간경과분 특례의 배제사유로 삼는 것은 적절하지 않다. 면책이 취소되는 경우에는 그 취소의 효력에 따라 기간경과분에 관한 특별면책도 유지되지 않는 것으로 규율하면 충분하다.

별도의 면책배제사유가 필요한 것은 조세면탈을 위하여 제도가 이용되는 경우이다. 다만 단순한 체납이나 신고지연만으로 특례를 배제해서는 안 되고, 해당 기간경과분의 기초가 된 본세와 관련한 적극적인 조세포탈행위를 객관적으로 확인할 수 있는 기준을 사용하여야 한다. 이에 국세의 경우 해당 기간경과분의 기초가 된 본세와 관련한 「조세

www.kci.go.kr

41) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제317조, 제384조 및 제545조.

범 처벌법」 제3조 제1항의 죄를, 지방세의 경우 「지방세기본법」 제102조 제1항의 죄를 특별면책의 배제사유가 되는 범죄로 정하되, 유죄판결의 확정시점과 면책결정의 확정시점 사이의 관계를 함께 규율할 필요가 있다. 본고는 면책결정이 확정될 때까지 해당 죄의 유죄판결이 확정된 경우에는 특별면책을 배제하고, 그 당시 이미 공소가 제기되어 형사재판이 계속 중인 경우에는 해당 조세채권에 관한 특별면책효만 그 형사절차의 결과가 확정될 때까지 유보하는 방식을 제안한다. 이는 조세범죄 일반을 이유로 특례를 배제하는 것이 아니라, 면책대상이 되는 기간경과분의 기초가 된 본세와 범죄행위 사이의 관련성을 요구하는 것이다. 이러한 기준은 헌법재판소가 조세 비면책의 정당화 근거로 제시한 조세면탈 목적의 제도악용 방지와 조세징수 확보라는 공익을 제한적 면책제도 안에서도 반영하기 위한 것이다.

조세포탈죄에 관한 형사절차가 면책절차보다 늦게 종료될 가능성도 고려하여야 한다. 면책결정이 확정될 당시 해당 본세와 관련한 조세포탈죄로 이미 공소가 제기되어 형사재판이 계속 중인 경우에는 해당 조세채권에 관한 특별면책효만 유보한다. 이후 유죄판결이 확정되면 특별면책을 적용하지 않고, 유죄판결이 확정되지 아니한 채 형사절차가 종국적으로 종료되면 그때 특별면책효가 발생하도록 한다. 반면 면책결정이 확정된 뒤에 비로소 공소가 제기된 경우에는 그 후 유죄판결이 확정되더라도 그 사실만으로 이미 발생한 특별면책효를 소급하여 상실시키지 않는 것으로 설계하는 것이 타당하다. 이를 달리 규율하려면 특별면책의 사후취소에 관한 별도의 절차・기간・효과를 마련하여야 하는데, 이는 제한된 범위의 개인책임만 조정하려는 본고의 입법모델을 지나치게 복잡하게 한다. 공소제기 시점을 기준으로 하면 면책확정 전후의 기소시점에 따라 결과가 달라질 수 있으나, 수사개시와 같은 불명확한 사실을 기준으로 특별면책효를 장기간 유보하는 것보다는 객관적인 기준시점을 설정하여 면책효의 법적 안정성을 확보하는 편이 타당하다. 다만 제569조의 별도 요건이 충족되어 일반 면책 자체가 취소되는 경우에는 그 취소의 효력에 따라 특별면책효 역시 유지되지 않는다.

지방세 납부지연가산세도 원칙적으로 동일한 입법취지 아래 정비할

www.kci.go.kr

필요가 있다. 현행 지방세기본법은 제55조 제1항 제1호의 기간비례분에 대하여 법정납부기한 경과 후 1일마다 납세의무가 성립하도록 하고, 같은 항 제4호의 금액에 대하여 납세고지서에 따른 납부기한 경과 후 1개월마다 납세의무가 성립하도록 정하고 있다. 제3호의 3퍼센트 정률분은 납세고지서에 따른 납부기한이 경과할 때 성립한다. 따라서 국세기본법 제47조의4 제1항 제1호·제1호의2에 대응하여, 지방세에서는 제55조 제1항 제1호·제4호의 기간경과형 납부지연가산세를 특례대상으로 정할 수 있다. 다만 국세와 지방세의 조문번호와 산정구조를 각 법률에 맞추어 명시하여야 하며, 채무자회생법 제473조 제2호의 관련 법률명은 「지방세기본법」이 아니라 「지방세징수법」임을 유의하여야 한다.[42]

마지막으로 개정규정은 시행 후 최초로 파산선고가 이루어진 사건부터 적용하는 것이 타당하다. 이번 입법은 면책효만을 변경하는 것이 아니라 기간경과분의 파산채권 편입과 배당순위까지 함께 변경하므로, 시행 당시 이미 파산선고가 이루어진 사건에 소급하여 적용하면 기존의 채권분류·배당관계와 절차참여자의 법적 기대에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 시행 당시 이미 파산선고가 이루어진 사건에는 종전 규정을 적용하고, 시행 후 파산선고 사건부터 제423조·제446조·제566조의 새로운 규율을 일체적으로 적용하는 것이 법적 안정성과 집행의 명확성에 부합한다. 이상의 설계를 조문화하면 다음과 같이 정리할 수 있다.[43]

---

42) 지방세채권의 도산절차상 우선적 보호와 그 배당·재기효과에 관하여 이주헌, “도산실무상 제기되는 지방세법상 쟁점”, 『지방세논집』 제7권 제2호, 2020, 156-158면. 현행 지방세 납부지연가산세의 성립시기와 산정구조에 관하여는 지방세기본법 제34조 제1항 제12호 나목·라목·마목 및 제55조 제1항 제1호·제3호·제4호 참조.

43) 비교법적 관점에서 일본「파산법」은 파산절차 개시 후의 연체세(延滯稅)·이자세(利子稅)·연체금(延滯金)의 청구권을 제97조 제3호에 따라 파산채권에 포함시키고, 이를 제99조 제1항 제1호에 따라 열후적 파산채권(劣後的破産債權)으로 취급한다. 이는 기간경과형 조세 부대채권을 파산절차에 편입하면서 일반 파산채권보다 후순위에 두는 본고의 입법모델과 구조적으로 대응한다. 日本國「破産法(平成16年法律第75号)」 第97條第3号·第99條第1項第1号(파산절차 개시 후의 연체세(延滯稅)·이자세(利子稅)·연체금(延滯金)의 청구권을

<표 1> 본 글에서 제안하는 채무자회생법 수정안 신·구조문대비표[44]

현행	개정안
제423조(파산채권)채무자에 대하여 파산선고 전의 원인으로 생긴 재산상의 청구권은 파산채권으로 한다. **제423조의2 -신설-**	**제423조(파산채권)** 현행유지 **제423조의2(납부지연가산세의 파산채권 특례)** ① 개인인 채무자에 대한 파산절차에서 파산선고 전에 성립하고 납부기한이 지난 국세 또는 지방세의 전부 또는 일부가 납부되지 아니하여 다음 각 호의 어느 하나에 따라 성립하는 납부지연가산세 중 제2항에 따른 특례대상기간에 대응하는 부분은 이 법의 적용에 관하여 파산채권으로 본다. 1.「국세기본법」 제47조의4제1항제1호 또는 제1호의2 2.「지방세기본법」 제55조제1항제1호 또는 제4호 ② 제1항에서 "특례대상기간"이란 파산선고일의 다음 날부터 제530조에 따른 파산종결결정이 있는 날 또는 파산폐지결정이 확정되는 날의 전날까지를 말한다. 다만, 제317조제1항에 따라

파산채권으로 포함시키고 열후적 파산채권(劣後的破産債權)으로 하는 규정), e-Gov法令檢索; 일본 국세청, 「第47條關係 差押えの要件」(파산절차 개시 후의 이자세·연체세를 열후적 파산채권으로 분류); 독일 도산법은 조세채무 전부를 일률적으로 비면책채권으로 취급하지 않고, 채무자가 해당 채무와 관련하여 조세법(Abgabenordnung)상 일정한 조세범죄로 유죄판결을 받은 경우에는 그 조세채무를 잔존채무면책의 대상에서 제외한다. 이하 Insolvenzordnung (InsO), §39 Abs. 1 Nr. 1 (도산절차 개시 후의 이자(Zinsen) 및 지연가산금(Säumniszuschläge)의 후순위화), §302 Nr. 1 (일정한 조세범죄와 관련된 조세채무의 잔존채무면책 배제), Bundesministerium der Justiz, Gesetze im Internet.

44) 현행 제473조제2호는 제446조에 따른 후순위파산채권을 재단채권에서 이미 제외하고 있으므로 본고의 입법모델을 실현하기 위한 필수개정대상에서는 제외한다.

www.kci.go.kr

현행	개정안
	파산선고와 동시에 파산폐지결정을 하는 경우에는 특례대상기간이 없는 것으로 본다. ③ 제1항 각 호의 납부지연가산세가 1개월 단위로 성립하는 경우 그 산정기간의 전부 또는 일부가 특례대상기간과 겹치는 때에는, 세법에 따라 성립한 해당 월별 금액에 그 산정기간의 총일수 중 특례대상기간과 겹치는 일수가 차지하는 비율을 곱한 금액을 제1항의 특례대상기간에 대응하는 부분으로 본다. ④ 제3항에 따른 일수의 산정, 단수처리 및 그 밖의 계산에 필요한 기술적인 사항은 대통령령으로 정한다.
제446조(후순위파산채권) ① 다음 각호의 청구권은 다른 파산채권보다 후순위파산채권으로 한다. 1. -현행- 2. -현행- **2의2-신설-** 3. -현행- 이하 생략	**제446조(후순위파산채권)** ① -현행- **2의2. 제423조의2제1항에 따라 파산채권으로 보는 납부지연가산세** 3. -현행-
제566조(면책의 효력)면책을 받은 채무자는 파산절차에 의한 배당을 제외하고는 파산채권자에 대한 채무의 전부에 관하여 그 책임이 면제된다. 다만, 다음 각호의 청구권에 대하여는 책임이 면제되지 아니한다. 1. 조세 이하 생략 ② 신설	**제566조(면책의 효력)**① 면책을 받은 채무자는 파산절차에 의한 배당을 제외하고는 파산채권자에 대한 채무의 전부에 관하여 그 책임이 면제된다. 다만, 다음 각호의 청구권에 대하여는 책임이 면제되지 아니한다. 1. 조세 이하 현행과 같음 ② 제1항 단서 제1호에도 불구하고,

www.kci.go.kr

현행	개정안
	면책을 받은 채무자는 제446조제1항제2호의2에 따른 청구권 중 파산절차에 의한 배당이나 그 밖의 변제로 소멸하지 아니한 부분에 관하여 책임이 면제된다. 다만, 해당 청구권의 기초가 된 국세 또는 지방세에 관하여 「조세범 처벌법」 제3조제1항 또는 「지방세기본법」 제102조제1항의 죄로 면책결정이 확정될 때까지 유죄판결이 확정된 경우 또는 제3항에 따른 형사재판에서 해당 죄로 유죄판결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
③ 신설	③ 면책결정이 확정될 당시 제2항 단서의 죄에 관하여 공소가 제기되어 형사재판이 계속 중인 경우에는 해당 청구권에 관한 제2항 본문의 효력은 그 형사절차가 유죄판결의 확정 없이 종국적으로 종료한 때에 발생한다.
부칙 신설	부칙 제1조(시행일)이 법은 공포 후 ○개월이 경과한 날부터 시행한다. 제2조(적용례)제423조의2, 제446조제1항제2호의2 및 제566조제2항·제3항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 파산선고가 이루어진 사건부터 적용한다.

www.kci.go.kr

Ⅴ. 결론

본 글은 파산선고 전에 성립하여 납부기한이 경과하였으나 미납된 본세를 전제로, 파산선고 후 시간의 경과에 따라 성립하는 납부지연가산세의 절차상 지위와 면책 여부를 검토하였다. 현행 국세기본법은 이 금액의 납세의무를 일별 또는 월별로 별도로 성립시키고 있으므로, 구 가산금·중가산금에 관한 대법원 2017. 11. 29. 선고 2015다216444 판결의 결론을 그대로 적용할 수는 없다. 그럼에도 세법상 납세의무의 성립시기와 채무자회생법 제423조의 '원인'은 서로 다른 판단기준이다. 파산선고 전 이미 본세가 성립하고 납부기한이 경과하여 미납상태에 있었다는 사정이 선고 후 기간경과분의 주요한 발생원인을 이룬다고 본다면, 이를 제423조의 파산채권으로 편입하고 그 지연보전적 기능에 따라 제446조의 후순위파산채권으로 분류하는 해석이 보다 타당하다. 다만 국세기본법 제21조가 각 기간분에 별도의 납세의무 성립시기를 정하고 있다는 점에서 반대해석의 가능성이 남으므로, 이러한 파산채권성은 입법을 통하여 명확히 할 필요가 있다.

이러한 절차상 분류만으로 면책 여부까지 결정되는 것은 아니다. 후순위파산채권도 파산채권이므로 원칙적으로 제566조 본문의 적용대상에 포함되지만, 기간경과분이 같은 조 단서 제1호의 '조세'에 해당하는 한 현행법에서는 책임이 면제되지 않는다. 반대로 이를 비파산채권으로 해석하는 경우에는 애초 제566조 본문의 면책효가 미치지 않는다. 따라서 파산채권성에 관한 어느 해석을 취하더라도 현행법만으로 파산선고 후 기간경과분에 대한 제한적 면책을 안정적으로 도출하기 어렵다는 점에서 입법적 조정의 필요성이 생긴다.

이 문제의 핵심은 조세채권 일반의 우선성이나 비면책성을 부정하는 데 있지 않다. 파산선고 후에는 파산재단에 속하는 재산의 관리·처분권이 파산관재인에게 전속되어 채무자가 그 재산을 이용한 본세의 변제를 스스로 결정할 수 없는 반면, 본세의 미납이 계속되는 동안 기간경과분은 추가로 성립하고 그 미변제잔액은 면책 후에도 채무자의 개인책임으로 남을 수 있다. 이러한 '변제통제와 책임의 불일치'는 본세

및 파산선고 전까지 성립한 조세부담의 비면책성을 유지하면서도, 재단재산에 관한 변제통제가 채무자에게 있지 않았던 기간에 대응하는 부대부담을 별도로 조정할 이유가 된다. 이는 조세 비면책 원칙을 전면적으로 완화하려는 것이 아니라, 그 원칙이 미치는 범위를 채권의 발생구조와 채무자의 통제가능성에 따라 한정적으로 조정하려는 것이다.

이에 본 글은 기간경과분의 세법상 성립 자체를 정지하는 방식보다 '절차편입・후순위화・제한적 면책형'을 채택하는 것이 적절하다고 본다. 이 방식은 조세채권 자체를 존속시켜 파산절차에서의 배당가능성을 보존하면서, 일반 파산채권보다 후순위에 두어 다른 파산채권자의 배당을 보호하고, 최종적으로 면책효가 인정되는 경우에만 미변제잔액에 관한 개인책임을 제한할 수 있다. 이를 위해 파산채권 편입에 관한 특칙, 제446조상 후순위 규정 및 제566조상 제한적 면책특례를 연계하여 마련할 필요가 있다. 현행 제473조 제2호는 제446조에 따른 후순위 파산채권을 이미 재단채권에서 제외하고 있으므로 이를 본고의 입법모델을 실현하기 위한 필수적인 개정대상으로 볼 필요는 없다.

특례의 대상은 본세 자체가 아니라 파산선고 전 성립한 본세의 미납을 전제로 파산선고 후 특례대상기간에 대응하여 성립하는 기간경과형 납부지연가산세로 한정되어야 한다. 본세, 파산선고 전 기간에 대응하는 금액, 정률적으로 부과되는 부분 및 독촉비용 등은 현행의 법적 취급을 유지한다. 월별 성립분은 세법상 납세의무 자체를 다시 분할하는 것이 아니라 세법에 따라 성립한 금액을 도산법상 특례대상기간에 귀속시키는 방식으로 처리하고, 동일한 발생구조를 가진 지방세도 병렬적으로 정비할 필요가 있다. 또한 개정규정은 시행 후 최초로 파산선고가 이루어진 사건부터 적용함으로써 기존 사건의 채권분류와 배당관계를 변경하지 않는 것이 타당하다. 이러한 제한적 조정은 국가의 조세채권과 파산절차상 배당가능성을 가능한 범위에서 보존하면서도, 개인파산의 공동변제와 경제적 재기라는 목적 사이의 불균형을 줄이는 하나의 입법적 방안이 될 수 있다.

www.kci.go.kr

참고문헌

1. 국내문헌

[단행본]

노영보, 『도산법강의』 제2판, 박영사, 2024.

전대규, 『채무자회생법』 제10판 제2권, 법문사, 2026.

전병서, 『도산법』 제5판, 박영사, 2024.

전선주, 「제473조」, 『주석 채무자회생법』 제2판 제4권, 한국사법행정학회, 2025.

정현수, 「제423조」, 『주석 채무자회생법』 제2판 제4권, 한국사법행정학회, 2025.

_____, 「제446조」, 『주석 채무자회생법』 제2판 제4권, 한국사법행정학회, 2025.

서울회생법원, 『개인파산관재인 직무편람』 제4판, 2024.

국회예산정책처, 『2025년 개정세법 심의 결과 및 주요 내용』, 2025.

[논문]

강상우, "파산선고 전의 원인으로 인한 조세채권에 기하여 파산선고 후에 발생한 가산금의 법적 성질", 『영남법학』 제48호, 2019.

김성용/오수근, "도산법에 대한 법경제학적 고찰", 『법경제학연구』 제8권 제1호, 2011.

손흥수, "민사집행절차, 도산절차상 조세채권의 취급과 그 비교 검토", 『사법』 제1권 제49호, 2019.

엄덕수, "파산절차가 민사집행 및 조세징수에 미치는 영향", 『법무연구』 제9권, 2022.

이의영, "도산절차에서 조세채권의 지위(하)", 『법조』 제58권 제7호, 2009.

이주헌, "도산절차상 가산금의 지위", 『사법』 제1권 제46호, 2018.

_____, "도산실무상 제기되는 지방세법상 쟁점", 『지방세논집』 제7권

www.kci.go.kr

제2호, 2020.
임치용, “재단채권에 기한 이행소송과 강제집행은 가능한가”, 『법조』 제54권 제12호, 2005.
정지선/이기욱, “기업의 도산과 조세채권의 취급”, 『법과정책연구』 제13권 제1호, 2013.
주진암, “도산절차에서 가산금 · 중가산금의 지위”, 『법조』 제57권 제10호, 2008.
최성근, 『도산절차의 형평성 확보를 위한 법제개선방안』, 한국법제연구원 연구보고 04-11, 2004.

www.kci.go.kr

Abstract

Procedural Status and Discharge of Late-Payment Penalty Tax Accruing after a Declaration of Bankruptcy in Personal Bankruptcy Proceedings

Kim Min Gyu
Attorney-at-Law; External Research Fellow, Center for Insolvency Law, Korea University

Park Byungjae
Intern, Office of the Individual Rehabilitation Commissioner, Seoul Bankruptcy Court

The Framework Act on National Taxes, amended December 23, 2025 and effective July 1, 2026, provides that the elapsed-period portion of the late-payment penalty tax accrues daily or monthly. This Article examines whether, where the principal tax established before a bankruptcy declaration remains unpaid, the penalty tax accruing from the mere passage of time after declaration is a bankruptcy claim, a subordinated bankruptcy claim, or an estate claim, and whether it is dischargeable.

At issue is whether Supreme Court Decision 2015Da216444, treating the post-declaration portion of the former surcharge as a subordinated bankruptcy claim, applies under current law. Given the structure of Articles 423 and 446 of the Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act and the compensatory character recognized in that decision, the elapsed-period portion should be a subordinated bankruptcy claim, not an estate claim.

Article 21 nonetheless leaves room for a contrary reading, and even as a subordinated claim, tax remains excluded from discharge under Article 566,

www.kci.go.kr

proviso, subparagraph 1. The core problem is a mismatch between control and liability: the debtor cannot control estate repayment after declaration, yet the unpaid penalty survives discharge as personal liability. This Article proposes procedural inclusion, subordination, and limited discharge, with linked amendments to Articles 423, 446, and 566.

Key words : individual bankruptcy, late-payment penalty tax, bankruptcy claim, subordinated bankruptcy claim, estate claim, tax nondischargeability

www.kci.go.kr